

1507277-67.2022.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507277-67.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507277-67.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212330/2022 - 01º D.P. AMERICANA, 26566763 - 01º D.P.

AMERICANA, 2212330 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado, Averiguado e Réu:

A APURAR (INDEFINIDO POR ORA) e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

NYCOLAS MARTINS ZAVATA GRAMINHOLI foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, 'caput', da Lei 11.343/06, acusado de no dia 04 de agosto de 2022, às 16h20, na Rua do Azulão, altura do numeral 200, bairro Jardim dos Lírios, nesta cidade, trazer com ele, para fins de traficância, 15 porções de maconha (TETRAHIDROCANNABINOL - THC), pesando cerca de 25,9g e 12 porções de cocaína, pesando 2,8 gramas, substâncias causadoras de dependência química, prontas para a venda e entrega ao consumo de terceiros e que provocam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa e acusação.

A denúncia foi recebida em 20/10/2022 (fls. 180/181) e o réu citado (fls. 219).

Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns e uma testemunha de Defesa.

Ao final, o réu foi interrogado.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu a procedência da denúncia, alegando provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime (fls. 232/236).

A Defesa, em memoriais, alegou ser nulo o processo, por prova ilícita de atuação da Guarda Municipal, que extrapolou as suas atribuições. A apreensão dos entorpecentes próximos ao acusado decorreu de atuação ilegítima da Guarda Municipal. A nulidade comprometeria a ação penal. No mérito, as provas seriam insuficientes. Com o acusado não foi encontrado nenhum ilícito ou valores. O réu não foi pilhado em ato de mercancia, além de não serem apreendidos apetrechos que configurem, de fato, a prática da traficância. Alternativamente, desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. A quantidade ínfima de droga também revela a natureza de consumo e não de tráfico. Para o caso de condenação, pena mínima, pois a única anotação seria por infração ao artigo 28, da Lei de Drogas. Reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo e recurso em liberdade (fls. 240/252).

É o relatório.

DECIDO.

Rejeito a arguição preliminar.

A qualquer do povo é dada a prisão em flagrante, em especial aos guardas civis, que estavam no exercício regular de função, conforme relato, com patrulhamento em praça pública.

Na jurisprudência recente do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL Ação Penal Preliminar Alegação de nulidade da prisão em flagrante efetuada por integrantes da guarda municipal Inocorrência Qualquer pessoa, no exercício da cidadania, pode efetuar prisão em flagrante Dicção do art. 301 do Código de Processo Penal Conquanto a guarda municipal não esteja investida de atividade de polícia preventiva, pode atuar em caráter secundário na pacificação social, prevenção e inibição da prática delitiva, mormente quando ocorrida em locais e condições que estão sob sua esfera de proteção Inteligência do art. 5º, incisos III, IV, V, XIV e XVI, da Lei nº 13.022/2014 Preliminar afastada Apelação Criminal nº 1502519-56.2021.8.26.0544, da Comarca de Itatiba, sessão permanente e virtual da 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 26 de outubro de 2022. XISTO RANGEL Relator(a).

De ver que no particular não ocorreram diligências típicas de polícia, como busca domiciliar ou quebra de dados telemáticos, mas de realização de prisão em flagrante, ainda assim quando os servidores públicos municipais desempenhavam função regular, de patrulhamento em vias da cidade e praça pública.

Até mesmo no C. STF, onde há repercussão geral a respeito do tema instalada (ainda não concluída - EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.

ATRIBUIÇÕES DE GUARDA CIVIL METROPOLITANA. DISCUSSÃO ACERCA DOS LIMITES E ALCANCE DA RESERVA LEGAL CONTIDA NO ART. 144, § 8ª, DA LEI MAIOR. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS E SEGUROS PARA NORTEAR A ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE ESPECÍFICO E DE ALCANCE GERAL. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DO PLENÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA), em recente voto vencedor do Ministro Luiz Roberto Barroso (que reconheceu ilegalidade na atuação investigativa de guarda civil), foi por ele enfatizado:

"...A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida." A

G .REG. NOS EMB .DECL. NO A G .REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.281.774 SÃO PAULO
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ROBERTO BARROSO 0
Decisão: A Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental interposto pela
Defensoria Pública de São Paulo, para o fim de negar provimento ao recurso
extraordinário e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo, no sentido da absolvição do ora agravante, nos termos do voto do Ministro
Luís Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Alexandre de
Moraes, Relator, que negava provimento ao agravo. Primeira Turma, Sessão Virtual de
3.6.2022 a 10.6.2022.

A questão, pois, está muito distante do que genericamente se procura atribuir como
nulidade na atuação da Guarda Civil Municipal, o que se espera seja definido na
repercussão geral referida. Sem embargo, há de se distinguir situações, lembrando
que o caso dos autos se refere a prisão em flagrante por guarda civil municipal e
não de diligências pretéritas e ao depois consumação de prisão em flagrante.

Pelo que se depreende dos autos, o réu estava em situação que exigia intervenção
dos agentes da autoridade, que resultou na apreensão de droga.

Havia indicativo de ocorrência de crime, em tese, que é permanente (tráfico) para a
realização da prisão em flagrante (não para a busca ou revista, como é a hipótese)
assim, sofre atenuação pelo interesse coletivo em se apurar, prevenir e punir a
prática de crime.

A abordagem não foi gratuita ou ocasional, mas movida por patrulhamento preventivo.
De lembrar, também, que estando o agente de autoridade no regular exercício da
função preventiva, exatamente para proteção do coletivo, não carece de mandado para
abordar e revistar, segundo o critério da discricionariedade imediata que lhe
confere o Estado para cumprir o mister.

Bem daí a regra do artigo 244 do Código de Processo Penal:

Art. 244. A busca pessoal independe de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar.

Apenas provado despropósito na ação profissional desenvolvida, o que não ocorreu e
foi produzido em termos de prova, pode dar ensejo à nulidade perseguida pela
Defesa.

Incontroverso, também, que o policiamento preventivo e a revista imediatamente
realizada resultaram em apreensão de drogas.

Não se tratou de busca investigativa, quando o objetivo estatal, por meio de seus
agentes, é relacionar a pessoa abordada a crime ocorrido, exigindo-se então a
fundada suspeita a legitimar a ação.

Diversamente, como é o caso destes autos, a busca preventiva se dirige a fundada
suspeita, portanto, funciona como garantia de que a pessoa não será,
aleatoriamente, relacionada à prática de uma infração penal investigada, sem
possuir relação com o fato.

Já a busca preventiva visa manter a ordem pública, evitar ilícitos, dar efetividade
às leis e se dirige a todos, indistintamente.

Exigir fundada suspeita sem distinguir a finalidade da ação estatal é desconsiderar
texto legal vigente, além de inverter a consideração de presunção de legitimidade
dos atos realizados pela administração pública e seus agentes, para considera-la em
regra abusiva.

No mérito, a ação penal é procedente.

Verifica-se dos autos que o réu foi preso em flagrante delito e na fase
administrativa permaneceu em silêncio (fls. 10).

"Na real verdade, preso naquelas circunstâncias a que a tradição do direito chama
'certeza visual do crime' (cf. Tostes Malta, do flagrante delito, 1933, p. 25), e
permanecendo calado na Polícia (fl.7), em vez de repelir, com a última força, a
imputação, como fazem os inocentes, apenas o decreto condenatório poderia atender a
um tempo à prova dos autos, à razão lógica e aos ditames da Justiça. Cai a lança
aquilo de Peter Thorton: 'A inocência pelo direito de falar; a culpa, essa invoca o
privilegio do silêncio' (Justice on trial, p. 36; Revista da Escola Paulista da

Magistratura, 2, p. 117). Impossível dizer melhor!" (TACRIM SP, 15ª C. - AP 1.286.483/3 - Rel. Carlos Biasotti, j. 07.02.2002, rolo-flash 1472/110).

"Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência não se reservar para prestar esclarecimentos apenas em Juízo." (Ap. Crim. 1070141/5, Taubaté, Rel. Renato Nalini, TACRIM SP, j. em 20.10.1997).

"PROVA. Interrogatório policial. Silêncio do réu. Valor. O silêncio do réu, quando interrogado na fase policial, direito constitucional que lhe foi assegurado, é comprometedor, pois o inocente brada desde logo sua inocência e apresenta eventual álibi ou justificativa de seu ato." (TACRIM SP, AC 1.288.149/1, SP, 8ª Câmara, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 13.12.2001).

Em Juízo, alegou que morava em Nova Odessa, vendia roupas. No dia 04 de agosto foi com a sua esposa até a residência da Raila, em Americana, para levar as roupas que ela havia encomendado. Sua esposa alegou que estava com fome, pediu para que comprasse algo para ela comer. Quando estava na Rua Andorinhas, próximo da Rua das Violetas, a viatura da Guarda virou bruscamente ao seu lado, quase foi atropelado. Ficou assustado e fugiu do local. Quando estava na altura da Rua Azulão X Violeta, a viatura da Romu passou por cima da guia da calçada e tentou o prensar contra a parede do comércio. Estourou o pneu da viatura, pulou por cima do veículo. Outra viatura da ROMU o abordou, deitou no chão. Não tinha nada de ilícito. Acreditava que pelo fato deles terem estourado o pneu da viatura e colidido contra o muro do comércio, os guardas pisaram na sua cabeça e nas suas costas, enquanto era algemado. Não resistiu. Desconhecia os entorpecentes, apenas foi vender roupas e saiu para comprar alimento para a sua esposa. Somente tomou ciência das drogas quando já estava detido, na Delegacia.

A negativa do réu não convence.

A testemunha guarda municipal Wilson Júnior Rodrigues se recordou de que estavam em patrulhamento e houve informação de que um denunciante pedia ajuda e enviou um vídeo, relativo ao tráfico, próximo da residência dele. As imagens eram de pequena duração, para ver quem estava fazendo a suposta condução da droga. Os entorpecentes saíam da Rua Andorinha, 206, eram levados até a Rua Violetas com Azulão, para ser vendida. Com as informações e as características visualizadas nas imagens enviadas, patrulharam pela Rua Azulão com Violetas, encontraram o Nycolas e o Thierry. Ao perceberem a viatura, Nycolas correu para um lado, enquanto Thierry correu para o outro lado. A sua equipe acompanhou o Nycolas, que foi dispensando drogas pelo caminho. Lograram êxito em o abordar, fizeram o trajeto inverso percorrido e localizaram certa quantia de drogas, maconha e crack. Foi até a Rua Andorinhas, local em que o subinspetor Antunes e o F. Barbosa abordaram o Thierry, na residência, numeral 206. A moradora, Alana, foi cientificada da denúncia, ela disse que nada temia e franqueou a entrada das equipes. Na área da frente da residência, foi localizado no bolso de uma jaqueta, que estava pendurada, 200 e poucas porções de crack, maconha e cocaína.

Dentro do imóvel encontraram em uma sacola, uma espécie de tupperware, R\$ 2.570,00 e poucos reais, em notas diversas. Alana falou que desconhecia sobre a existência de drogas no imóvel. Questionada a respeito do dinheiro, ela falou que R\$ 1.500,00 pertencia a ela, de um benefício que a tia deficiente recebeu. A mulher nada informou sobre o restante do dinheiro. Indagada sobre uma balança, que estava perto do dinheiro, no guarda roupa, Alana afirmou que a balança pertencia ao marido, que estava preso. Alana contou que o Thierry procurou abrigo no imóvel em razão dele ser amigo do seu marido. Eles foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, para lavratura do auto de prisão em flagrante. Estava na viatura Gol, prefixo 199. O acusado foi abordado pela sua equipe, mas foi conduzido até a Delegacia pela viatura da ROMU.

Suellen de Oliveira Tomaz, outra guarda, ratificou a versão em uníssono, harmônica e coerentemente. Destacou que o controle da Guarda informou uma denúncia de tráfico, que descrevia que um homem buscava drogas na Rua das Andorinhas, na casa, numeral 206. Diligenciaram até a Rua do Azulão, avistaram duas pessoas, um deles possuía as características descritas na denúncia. Ao avistar a viaturas, os

implicados correram para lados opostos. Nycolas foi abordado e revistado; nada de ilícito foi localizado. Porém, no trajeto da fuga, que foi na mesma rua, encontraram 15 porções de maconha e 12 porções de crack. O Thierry correu do lado oposto, ele procurou refúgio em uma residência, numeral 206, pela Rua das Andorinhas. Ele foi abordado já no quintal da residência, com a quantia de R\$ 50,00 e um telefone celular, da marca Apple. Alana, proprietária da residência, apareceu e foi informada dos fatos e franqueou a entrada das equipes na casa. Durante as buscas realizadas, localizou no quintal, uma jaqueta pendurada. No bolso da blusa, havia 217 porções de crack, 125 porções de maconha e 14 papелotes de cocaína. A proprietária alegou que desconhecia a existência da droga e permitiu que o imóvel fosse vistoriado. No quarto, localizou no armário, em uma tupperware, a quantia de R\$ 2.574,30, em notas diversas e moedas, além de uma balança de precisão. Questionada a respeito do dinheiro e da balança, a moradora informou que R\$ 1.500,00, era benefício de uma tia, que morava com ela. O restante do dinheiro, a mulher disse que não tinha conhecimento.

Alana disse que a balança era do seu marido, que estava preso. Thierry era amigo do marido da Alana. Diante dos fatos, eles foram conduzidos até a delegacia de polícia. Estava na viatura, prefixo 199, modelo Gol. Já tinha abordado o Nycolas anteriormente, mas não tinha encontrado nada com ele. Na ocasião, a equipe acompanhou o Nycolas e viram quando ele dispensou a droga, pelo caminho.

A testemunha de Defesa, Raila Caroline da Silva, explicou que comprava roupas do acusado, eram conhecidos há quatro anos. Nycolas chegou de moto na sua casa, junto com a esposa, perto do horário do almoço. Eles foram entregar as roupas que havia encomendado. Uma viatura se aproximou, os guardas ficaram encarando a sua casa, até que entraram no imóvel. A esposa do Nycolas ficou esperando, enquanto experimentava as peças e pediu para o Nycolas buscar alguma coisa para ela comer. Após dez minutos receberam ligação para informar sobre a abordagem. Foram até o local, o policial estava com o pé na cabeça do Nycolas, que estava deitado no chão. Ele não estava com drogas.

Não há como prestigiar a versão do réu e da sua companheira, em confronto com o seguro depoimento dos guardas civis.

Quando patrulhavam o bairro, transeunte inconformado com o tráfico reclamou para a Guarda Civil Municipal, inclusive com filmagem que permitia a visualização do suspeito.

Ao depois, avistado, o réu suspeitosamente tratou de empreender fuga, mas restou detido e abordada droga em quantidade e variedade que convencem se destinavam ao tráfico.

A droga estava em kits, o réu tentou se desfazer, em vão, delas.

Finalmente abordado, nada levava, mas o embrulho dispensado, revelou que o réu jogou vários kits de entorpecentes.

Os guardas apresentaram versões firmes e coerentes, todas revelando que o réu foi mesmo quem dispensou tanto expressivo de droga. Também levava dinheiro, sem procedência lícita provada.

As circunstâncias da prisão em local já conhecido como ponto de tráfico; a denúncia com descrição e imagens do acusado, a apreensão das drogas, já embaladas em pequenas porções, prontas para a venda e entrega ao consumo de terceiros; tentativas de fuga do acusado, que foi imediatamente perseguido e detido pelos guardas civis, com suspeitosa dispensa de sacola, evidenciam que ele trazia a droga para o tráfico.

A conduta é mesmo a de tráfico, não sendo necessário, para a hipótese, que o réu estivesse vendendo drogas. A acusação é pontual em alegar que trazia com ele, drogas para a mercancia.

Trata-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as

condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

Indiferente a alegação do réu, assim, de que não teria envolvimento com o tráfico, na conduta de vender o entorpecente, ainda que desmentida pelos guardas municipais, na medida em que a acusação é certa de imputar a ele a conduta de trazer com ele, para esse fim, que poderia por evidente (a venda) ser realizada por terceira pessoa, que não identificou.

A prova, enfim, é boa e suficiente, com prisão em flagrante delito, certeza visual do delito, apreensão da droga e depoimentos de guardas civis.

Não há de se colocar ressalvas no depoimento de guardas municipais tão só por essa condição.

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (HC no. 5J.577; DJU 7.12.73, p. 9.372; apud Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, 22a. ed., p. 187).

"Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após foram compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tudo por vil escopo de inculpar inocente" (RT 411/266; no mesmo sentido, STF, HC 73.518-SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF, HC 74.608 SP., Rel. Min. Celso de Mello).

Merece transcrita a lição do Des. ARY BELFORT: "A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia - há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP vol. 136, pág. 477).

Sequer fez prova da versão exculpatória, como lhe incumbia.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o alibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao inculpatado o ônus de sua demonstração" (Da prova no processo Penal, editora Saraiva, 7ª ed. 2006, p.18).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor:

"O alibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

A respeito, já se decidiu que "de acordo com a jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o alibi apresentado." (STJ, 5ª Turma, Habeas Corpus nº 44.376/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 17.11.2005).

Ressalta-se, no ponto, que a mulher do réu, além do interesse em beneficiar o companheiro, admitiu que não presenciou a abordagem e da prisão foi informada apenas depois de sua ultimização.

Também o fato de ser usuário de drogas não afasta a traficância, quando o porte de

eventual droga é absorvido pelo crime de maior severidade, no caso, o tráfico. Inclusive, é rotineira a alegação de mero uso, antes evidenciando o propósito desmedido de usuários, para satisfação de vício, dignarem-se a transportar drogas ou até procederem a venda, com retenção de parte (como paga) para consumo. Não é improvável que o réu assim tivesse agido, o que é indiferente pela prova segura de que trazia com ele droga alentada para esse fim.

Por evidente, o princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, crime de perigo abstrato e em que é irrelevante a quantidade da substância apreendida (neste sentido, 5ª T. STJ, Rel. Min. Jorge Mussi, REsp 1.637.113).

A materialidade da infração foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), pelo laudo de constatação de fls. 30/32, 33/35, 36/38, 39/41 e 44/44, bem como pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 100/102, 103/105, 106/108, 109/111 e 112/114).

Bem típica a conduta, pois, que merece severa punição.

Fixação das penas.

O réu é tecnicamente primário, pois a condenação no Processo nº 0002252-84.2018.8.26.0344, da 1ª Vara Criminal do Foro de Marília pelo artigo 28, "caput" do SISNAD (fls. 39) é inábil para a reincidência (PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. AGRAVANTE AFASTADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (AgRg no HC 602.724/SP, 5ª T. Rel. ministro Ribeiro Dantas). Fixo a pena base no mínimo legal. Na segunda, não há circunstância a ser considerada, repetido que a condenação no Processo nº 0002252-84.2018.8.26.0344 pelo artigo 28, "caput" do SISNAD não gera reincidência. Mantenho inalterada a pena base.

Na terceira e última fase, sem comprovação de que se dedicasse a atividade criminosa e nem integrasse organização criminosa, reduzo a pena em metade, assim a tornando definitiva, justificando-se o percentual pela nocividade da droga e as circunstâncias que nortearam a infração.

É de se impor o regime inicial aberto, pela somatória da pena, reclusiva.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal.

Depois, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que: "Esta Corte, na esteira do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto." HC nº 239.999/MS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.08.2014.

Na mesma evolução, com a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (popularmente conhecida como "pacote anticrime"), houve necessidade de maior reflexão pelos julgadores. Dentre as alterações previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de Execuções Penais, em especial no tocante ao "tráfico privilegiado": Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...) § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu para condenar a NYCOLAS MARTINS ZAVATA GRAMINHOLI, às penas de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, regime inicial aberto e duzentos e cinquenta (250) dias-multa, piso mínimo da Lei de drogas, por infração ao artigo 33, 'caput' e parágrafo 4º, ambos da Lei número 11.343/2006.

Presentes os pressupostos legais, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena e mais prestação pecuniária, que arbitro em um (01) salário-mínimo.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Condene o réu nas custas do processo, que arbitro em 100 UFESPs, na medida em que constituiu advogado, sem comprovação de que fosse hipossuficiente.

Vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, bem como os objetos apreendidos, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Preso pelo processo, expeça-se alvará de soltura, incompatível a substituição ora operada com a prisão vigente. Faculto recurso em liberdade.

Após o trânsito, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 25 de novembro de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA